

1501379-05.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE DA FONSECA TAVARES

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... do flagrante para restar configurado o crime de tráfico de entorpecente.

Isso porque o crime de tráfico é de perigo abstrato, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: "o tráfico ilícito de entorpecentes... é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

2ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501379-05.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501379-05.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213578/2022 - DEL.POL.MIRASSOL, 26593579 -

DEL.POL.MIRASSOL, 2213578 - DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Desconhecido e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. ANDRE DA FONSECA TAVARES

Vistos.

RIQUE JÚNIOR COLOMBO, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 06 de agosto de 2022, por volta das 09hs30min., na altura do número 2035 da Avenida Frei Antônio Zimerman, Jardim Alvorada, neste Município e Comarca de Mirassol, trazia consigo e transportou 2 (duas) porções de cocaína, com peso líquido de 49,6 gramas, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar para fins de tráfico ilícito.

A denúncia foi recebida no dia 31 de agosto de 2022. O acusado foi devidamente citado e apresentou defesa preliminar. Houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Houve audiência de Instrução e apresentação de memoriais pelo Ministério Público e pela Defesa.

É o relatório do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em primeiro lugar, transcrevo o tipo penal indicado na denúncia. Diz o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01), pelo termo de depoimento (fls.02/03, 04 pelo termo de declaração (fls.05), pelo Boletim de Ocorrência (fls.32/34), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls.42/43), pelo termo de interrogatório (fls.07), pela nota de culpa (fls.08), pelas fotografias (fls.44/46), pelo Laudo Pericial (fls.39/41, 82/84, 234/236, 237/242, 243/250), pelo ofício de encaminhamento de preso (fls.47), pelo Relatório Final da Autoridade Policial (fls.103/104), bem como pela prova oral produzida. Passo à análise da autoria.

O policial militar LEONARDO falou na delegacia que "estava de serviço, junto de seu colega de trabalho, ora testemunha, quando por volta das 09:30 horas, avistaram um indivíduo em pé encostado em um veículo Fiat/Idea; que ao perceber a presença da viatura policial tentou entrar no veículo ao lado do passageiro; que ao proceder a verbalização e dar início a abordagem o suspeito, agora identificado como RIQUE, falou: "perdi, senhor, sic", indicando que havia droga no bolso de sua calça; que realizada busca pessoal foi encontrada a referida droga e um aparelho de telefone celular; que indagado a respeito dos fatos, Rique, respondeu que havia buscado a droga em São José do Rio Preto, que ele fazia o serviço de entrega e que ele estava ali no local aguardando o indivíduo que ele não sabe dizer quem para lhe entregar a droga que estava em seu poder; que realizada busca pessoal no veículo no qual se encontrava no banco do motorista a pessoa de Juliana; que indagada sobre o que estava fazendo no local, respondeu que não sabia que seu marido estava com drogas, assim como desconhecia o fato dele estar esperando alguém para entrega-las, fatos confirmados por Rique; que diante dos fatos todos foram conduzidos até esta Delegacia de Polícia; que foram lidos seus direitos constitucionais; que foi necessário uso de algemas por receio de fuga; que Rique informou a senha de seu aparelho de telefone celular, bem como autorizou que ele fosse vasculhado". Em Juízo confirmou sua declaração, acrescentou ainda que "não é verdade que ameaçou de prender a mulher caso o réu não confessasse. O seu companheiro estava atrás do veículo aguardando alguém chegar. O réu se recusou a dizer quem era. A esposa do réu estava no banco do motorista. Ela falou que não sabia do fato".

O policial militar NILTON na delegacia confirmou o depoimento de seu colega de farda Luciano. Em Juízo confirmou sua declaração, acrescentou ainda que "o réu ofereceu a senha dos dois celulares, mas não se recorda se ele falou que eram deles. A esposa dele também foi conduzida até a DP. O veículo foi recolhido por falta de licenciamento".

A testemunha de defesa JULIANA, falou em juízo que "É esposa do réu e desconhece os fatos".

A testemunha de defesa CARLOS, falou em juízo que "tem clínica de internação e o réu e sua mãe lhe procuraram na sexta. Não fizeram a internação por falta de dinheiro, falando que voltariam segunda-feira".

O réu RIQUE, na delegacia de polícia disse que "que já realizou entregas de drogas em outra oportunidade; que na data de hoje foi contratado para pegar droga, mais especificamente cocaína, no centro da cidade de São José do Rio Preto-SP para entregar nesta cidade de Mirassol; que antes de realizar a entrega foi abordado por policiais militares; que confessa a traficância; que estava em contato com a pessoa que realizaria a entrega através de um aparelho de telefone celular, o qual revelou a senha e autoriza que ele seja vasculhado pela polícia; que ele não foi agredido e não apresenta lesões". Em juízo, o réu disse que NÃO é verdadeira a acusação.

Contou que "no dia dos fatos foi comprar a droga pois iria se internar e usaria durante a internação. Perguntou para o traficante 'boy' se tinha um celular para vender e este lhe passou um aparelho. Acabou experimentando a droga. Sua esposa percebeu e brigou. Quando foram abordados os policiais ameaçaram culpar sua esposa

caso ele não assumisse o crime. Foi o policial LEONARDO que lhe extorquiu. Não viu a autoridade policial. Nunca viu o policial LEONARDO antes e com ele não tem nenhuma desavença, sendo que o único motivo da extorsão é porque o policial queria determinada versão”.

Portanto, diante do que restou apurado, de rigor a procedência da ação penal. O réu negou o crime, mas não apresentou nada que poderia justificar falsa acusação dos policiais contra ele. Já os policiais foram firmes e uníssonos em seus depoimentos. Deram a mesma versão em juízo e na delegacia.

Não há, ainda, qualquer razão para se duvidar do relato dos agentes públicos, que não teriam motivos para acusarem o réu injustamente, sendo seus testemunhos válidos, com o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos, sendo inquestionáveis, até que se prove o contrário, por gozarem de fé pública e quando corroborado com os outros elementos de prova.

Além da palavra dos policiais, na delegacia o réu confessou que entregava drogas e que estaria fazendo naquela oportunidade, bem como estava em contato com a pessoa que as receberia. Foi apreendida uma porção expressiva de entorpecente com o réu, suficiente para fazer dezenas de porções individuais para venda.

Os exames químico-toxicológicos (fls.82/84) realizado nos entorpecentes encontrados com o réu resultou em positivo para “COCAÍNA”, substância de uso proscrito no Brasil.

Observo que a quantidade da droga e sua forma de acondicionamento demonstra a finalidade diversa do simples uso. Fica afastada, portanto, a tese para uso próprio, sendo irrelevante estar provada a existência de trabalho lícito, visto que a mercancia da droga pode coexistir com ele.

Importante registrar também que é desnecessária a demonstração da comercialização da droga no momento do flagrante para restar configurado o crime de tráfico de entorpecente.

Isso porque o crime de tráfico é de perigo abstrato, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “o tráfico ilícito de entorpecentes... é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo legislador na construção do tipo)... não se permite ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram à sociedade não ser conveniente à sociedade a circulação de determinadas tipos de drogas”. (Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed. 2007, Editora Revista dos Tribunais, p. 314/315).

Ou seja, é punida a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, portanto, não há necessidade de efetiva prática do ato de comércio da substância entorpecente com a finalidade de venda.

Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - TESES DEFENSIVAS: I) DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. II) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. III) REESTRUTURAÇÃO DA PENA. IV) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AS TESES DEFENSIVAS NÃO MERCEM ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Demonstrado que o réu guardava a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação por tráfico. 2. As provas produzidas ao longo da instrução são suficientes para ensejar a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo como acolher a pretendida desclassificação da conduta para a de uso próprio. 3. O tráfico de drogas é delito de perigo abstrato e presumido, criado com o fim de tutelar a saúde e segurança pública, não se restringindo à esfera pessoal do agente, ao contrário, atinge toda a coletividade, vez que estimula outras condutas criminosas, aumentando sobremaneira a violência em nossa sociedade, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância. 4. Inviável o acolhimento da pretendida reestruturação da pena, de acordo com o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que já fixada no patamar mínimo legal, após análise esmerada de cada um dos moduladores descritos no art. 59, do CP. 5. Impossível prosperar o pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea no caso em tela, eis que o acusado, na fase policial, silenciou-se e, em juízo, apesar de admitir que a droga era de sua propriedade, alegou que seria destinada ao uso e não ao tráfico, crime

este pelo qual restou condenado... O tráfico de drogas é delito de perigo abstrato e presumido, criado com o fim de tutelar a saúde e segurança pública (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Esse delito não se restringe à esfera pessoal do agente, ao contrário, atinge toda a coletividade, vez que estimula outras condutas criminosas, aumentando sobremaneira a violência em nossa sociedade. Daí porque não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância.". (Apelação Criminal 1.0480.11.006978-2/001; 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, RELATOR WALTER LUIZ DE MELO; j. 28/08/2012).

Ainda: "TÓXICOS - TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE - PROVA SUFICIENTE - INSIGNIFICÂNCIA - NÃO APLICAÇÃO - NEGATIVA DA AUTORIA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE - COMÉRCIO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS - REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A SUA APLICAÇÃO - FRAÇÃO - MANUTENÇÃO - REGIME PRISIONAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SUBSTITUIÇÃO DO ART. 44 DO CPB - CABIMENTO NO CASO CONCRETO. - Se, apesar de o réu negar a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, as provas são aptas a comprovar os fatos havidos na denúncia, correta é a condenação nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06. - A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para tornar a conduta atípica, uma vez que o delito de tráfico, enquanto delito de perigo abstrato, apresenta grande lesividade à saúde e à incolumidade pública, o que não pode ser graduado somente pela quantidade de entorpecente apreendida. - Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes e seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé. - Para a caracterização do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não exigindo a consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente. - É cabível a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos se o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. - A fração de redução de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, deve ser fixada de acordo com as regras do art. 59 do CPB daquela norma antidrogas. - Adotando o novo entendimento disposto quando do julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cabível é a concessão do regime prisional diverso do fechado nos casos de tráfico privilegiado. - Preenchidos os requisitos legais, cabe conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, mesmo no caso de tráfico de entorpecentes.". (Apelação criminal nº 1.0079.10.610239-9/001, 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, RELATOR CATTÁ PRETA, j. 04/09/2012).

Ainda, o laudo pericial de fls. 243/250, que periciou o telefone do réu possui provas da traficância, descrevo alguns trechos: "quanto sai" e a seguir há vários vídeos apresentando as substâncias aparentando ser entorpecente; na sequência: "olha aí, o material"... tava precisando arrumar um verde top e barato..." após é apresentado vários vídeos, e fotos do material e balança.

Diante de todo o exposto, considero que o réu praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, lembrando que a pena mínima nesse caso é de 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Na aplicação da pena, sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 62 da Lei de Drogas, verifico que o réu possui anotações (fls.48/51), porém serão consideradas na segunda fase da dosimetria da pena, assim, na primeira fase fixo a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls.49/50 - Processo 0000512-28.2018.8.26.0559), pelo que aumento a pena em 1/6, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, impossível aplicar a redutora do §4º do art. 33 da lei de drogas, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis (outra condenação pelo mesmo crime), pelo que torno a pena acima definitiva.

O regime carcerário será inicialmente o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º,

alínea "a", do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Cada dia multa deverá ser calculado no mínimo legal (um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente), diante da ausência de elementos quanto à situação econômica do réu, e o valor deverá ser corrigido no momento da execução.

O réu não tem direito a benefícios que substituem a pena privativa de liberdade, principalmente por não preencher os requisitos subjetivos do artigo 44, e do artigo 77, ambos do Código Penal. Além disso, aplica-se o disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06: "Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos".

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa do ofendido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e assim CONDENO o réu RIQUE JÚNIOR COLOMBRO, como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a cumprir a pena 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial FECHADO. A pena de multa deverá ser calculada no mínimo legal, conforme fundamentação acima, a ser atualizada pelos índices de correção monetária no momento da execução, nos termos do artigo 49, § 2º do Código Penal.

A prisão cautelar do réu deve ser mantida. A quantidade de entorpecentes apreendida em sua posse demonstra que seria impossível ficar em liberdade sem prejudicar a ordem pública, sendo também reincidente. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra.

Determino a destruição dos celulares (fls.42/43), nos termos do artigo 516, § 2º, NSCGJ.

Por fim, autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (Fls. 42/43) guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei nº 11.343/ 06, deverá ser observado o art. 32, § 2º que exige a presença da representante do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Custas "ex lege". Ao defensor nomeado, arbitro honorários nos termos do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil - SP em vigor. Expeça-se certidão.

P.I.C. Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Mirassol, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA